

1501273-86.2020.8.26.0438

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

"O crime de tráfico privilegiado de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501273-86.2020.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501273-86.2020.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

JACKSON APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado às fls. 16, foi denunciado e processado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, em tese, no dia 20 de junho de 2020, por volta das 12h00min, na Rua dos Flamingos, nº 52, Morada do Sol, na cidade de Avanhandava e Comarca de Penápolis, trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) porções de Cannabis Sativa L (maconha), correspondendo a 30,08 grama(s) - trinta gramas e oito centigramas; e 03 (três) porções da mesma substância, correspondendo a 1,79 grama(s), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na denúncia que o réu resolveu praticar o tráfico de drogas nesta cidade, mormente no local do fato. Para tanto, as substâncias eram adquiridas de terceiro, separadas e mantidas em seu poder e, depois, comercializadas. No dia e hora dos fatos, policiais militares faziam patrulhamento de rotina, quando, ao trafegarem pela Rua do Flamingo, na altura do numeral 52, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, visto que o denunciado passava algo para um adolescente. Pararam a viatura e realizaram a abordagem.

Ato contínuo, foi realizada busca pessoal e localizadas com o adolescente Athos Pereira Ferraz 1 (uma) porção de Cannabis Sativa L, conhecida como maconha, que acabara de receber do indiciado. Já com o denunciado havia um pote de plástico contendo em seu interior 03 (três) porções grandes da mesma substância, sem embalagem. Com JACKSON foi ainda encontrada a quantia de R\$ 8,00 (oito reais), em notas de dois reais, fruto da venda de drogas.

Citado/notificado (fl. 88), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 89).

A denúncia foi recebida no dia 6.12.2021 (fls. 91/96).

Durante a instrução, ouviram-se 2 (duas) testemunhas de acusação (fls. 121/122), sendo o réu interrogado ao final (fl.123).

Em Memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, porém não se insurge contra a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º, da LAD (fls. 118/120).

A Defesa do réu, postulou a absolvição, nos termos do artigo 386, V, ou então inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação do crime para o previsto no artigo 28 da LAD ou então aplicação da pena no mínimo legal (fls. 124/130).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) boletim de ocorrência (fls. 4/9); ii) auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); iii) laudo toxicológico (fls. 21/26).

A autoria também é certa, conforme se depreende da prova oral colhida.

A Testemunha/APM Eder Soares dos Santos disse que estavam em patrulhamento e, como motorista, viu o réu passando algo para um adolescente. Abordou ambos e, no bolso do réu, encontrou R\$ 8,00 e, com o menor, uma porção de maconha mais um pote de Nutella. Ambos confirmaram que era maconha que havia dentro e que era do Jackson, ainda não fracionada. O réu disse, que não estava vendendo, mas que estava fracionando para consumirem juntos. Conhecia o réu mas o menor não, pois era de fora e estava na cidade porque namorava uma prima do Jackson. Usuários disseram que já tinham adquirido dele, em ocasiões anteriores.

A Testemunha/APM Vinicius Rodrigues Ribeiro disse que estavam em patrulhamento pela rua e seu parceiro viu um sujeito passando algo para outro, em atitude suspeita. Em busca pessoal, encontraram no bolso do réu R\$ 8,00 e, num muro próximo a eles, um pote de Nutella com porções de maconha. Jackson disse que a maconha era dele e o outro disse que pegaram a maconha para fazerem cigarro e fumarem. Não lembra do réu ter justificado a origem do dinheiro. Fazia apenas 2 dias que o depoente estava trabalhando na cidade. Não conhecia o réu dos meios até então, porém, posteriormente, ouviu dizer que ele mexe com tráfico.

Em seu interrogatório, JACKSON APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS disse que estava na casa da sua Tia com o Atos, que namorava sua prima. Foram até à casa dele para pegar o pote de maconha e fumarem. Tirou uma porção do pote para fumar e a PM chegou. O dinheiro estava no bolso do Atos (não estava no bolso dele). Quando a PM chegou, Atos estava dichavando o baseado. Trabalha como servente de pedreiro. Na época dos fatos, fazia o mesmo serviço. Conseguia ganhar 1 salário mínimo por mês.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo.

Ambos PMS confirmaram que, ao ver o réu na companhia do então adolescente, viu-o repassando algo ao menor, apreendendo uma porção de maconha com ele e mais R\$ 8,00, além de outras porções da mesma droga em um pote de Nuttela, cuja propriedade foi assumida pelo acusado - embora diga que seria para consumo de ambos naquela ocasião.

Com efeito, o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

Assim, mostra-se claro que as demais porções localizadas no pote de plástico com o réu não se destinavam ao consumo de ambos, dele e do adolescente, uma vez que se tratavam, no total, de 11 porções de maconha, conforme auto de apreensão a fls. 10/11, sem contar que se trata de quantidade total relevante (30,08 gramas + 1,79 grama - cf. fls. 22 e 25).

Insta salientar que não ficou demonstrado nos autos motivo algum para que os policiais quisessem incriminar falsamente o acusado, imputando-lhe o delito de tráfico de drogas.

Por sua vez, o acusado não conseguiu trazer aos autos qualquer evidência que faça pairar dúvida sobre as provas acima exploradas.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Vejo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, a teor da sua primariedade. Ademais, a análise das circunstâncias judiciais tem por finalidade adequar a quantidade da pena às particularidades que envolvem o fato e o agente, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Sem agravantes ou atenuantes. Não há que se falar em confissão, pois, embora o réu reconheceu que a droga era sua, porém, por outro lado, alegando ser para consumo próprio e do adolescente.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da LAD, dado o envolvimento do adolescente Atos (fl. 14), pelo que aumento a pena de 1/6, perfazendo, assim, 5 (cinco) anos, 10 (meses) de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor.

Por outro lado, ante a primariedade do acusado e da ausência de indicativos de que ele integre organização criminosa ou se dedique à atividade ilícitas, vislumbro o cabimento da redução de pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diminuindo a pena em 2/3, considerando-se a a primariedade e os bons antecedentes indicados, perfazendo o montante de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no menor valor.

Pois Bem.

Na sessão do dia 23.6.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

“O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de “habeas corpus” para afastar a natureza hedionda de tal delito. No caso, os pacientes foram condenados pela prática de tráfico privilegiado, e a sentença de 1º grau afastara a natureza hedionda do delito. Posteriormente, o STJ entendera caracterizada a hediondez, o que impediria a concessão dos referidos benefícios v. Informativos 791 e 828. O Tribunal superou a jurisprudência que se firmara no sentido da hediondez do tráfico privilegiado. Sublinhou que a previsão legal seria indispensável para qualificar um crime como hediondo ou equiparado. Assim, a partir da leitura dos preceitos legais pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, “caput” e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos critérios gerais de punição. A legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da pena, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Essa previsão legal permitiria maior flexibilidade na gestão da política de drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a realidade pessoal de cada autor. Além disso, teria inegável importância do ponto de vista das decisões de política criminal.” (Informativo nº 831, STF. HC 118.833/MS, rel Min. Cármen Lúcia, 23.06.2016) (g.n.).

No mesmo sentido, o STJ, em 23.11.2016, por meio de sua 3ª Seção, por unanimidade, acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.329.088/RS - Tema 600, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior

Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016).

Diante disso, como decorrência lógica, e revendo entendimento anterior, não deverá, portanto, incidir no caso o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação dada pela Lei 11.464/07, que estipula como regra o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Isso porque, de forma incidental, o Plenário do STF já declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afirmando a possibilidade de o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min.Dias Toffoli, j. 27.06.2012).

Por fim, é cabível, em tráficos privilegiados, A DEPENDER DO QUANTUM DA PENA E DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito. Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Em suma, não é possível hoje desconhecer que, notadamente a partir de decisões de seu Tribunal Pleno (HC 97.256/RS Rel. Ayres Britto j. 01.09.2010 m. v.; Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 663.261/SP Rel. Luiz Fux j. 13.12.2012 m. v.), tal lição tem sido torrencialmente ministrada em julgados unânimes de ambas as Turmas julgadoras do Supremo Tribunal Federal, a quem, inclusive, incumbe o controle máximo da constitucionalidade em nosso País (2ª T HC 124.489/MG Rel. Teori Zavascki j. 10.03.2015; 1ª T RHC 123.080/BA Rel. Luiz Fux j. 21.10.2014; 1ª T HC 111.015/MS Rel. Luiz Fux j. 21.05.2013; 2ª T HC 115.174/RS Rel. Gilmar Mendes j. 02.04.2013; 1ª T HC 123.622/SP Rel. Luiz Fux j. 23.09.2014; 1ª T HC 120.876/SP Rel. Luiz Fux j. 1ª T HC 120.663/SP Rel. Rosa Weber j. 29.04.2014; 2ª T RHC 120.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 25.02.2014; 1ª T HC 116.641/SP Rel. Marco Aurélio j. 25.02.2014; 2ª T HC 118.935/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 26.11.2013; 1ª T HC 115.508/SP Rel. Marco Aurélio j. 05.11.2013; 2ª T HC 115.350/MS Rel. Gilmar Mendes j. 29.10.2013; 2ª T HC 115.153/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.09.2013; 2ª T RHC 111.059/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 05.06.2012; 2ª T HC 111.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012).

Não diverso tem sido também o entendimento unânime adotado pelas duas Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5ª T HC 298.792/SP Rel. Newton Trisotto j. 24.03.2015; 6ª T HC 213.412/ES Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015;

6ª T HC 187.874/MG Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 5ª T HC 308.380/SP Rel. Leopoldo de Arruda Raposo j. 05.03.2015; 5ª T HC 299.780/SP Rel. Newton Trisotto j. 03.03.2015; 6ª T HC 309.663/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 03.03.2015; 5ª T HC 291.136/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 307.913/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 306.352/SP Rel. Felix Fischer j. 12.02.2015; 6ª T HC 307.489/SP Rel. Ericson Maranhão j. 12.02.2015; 5ª T HC 301.120/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 292.602/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 297.405/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 6ª T HC 310.798/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 03.02.2015; 6ª T AgRg no AREsp 436.420/DF Rel. Sebastião Reis Júnior j. 03.02.2015; 5ª T HC 304.439/SP Rel. Felix Fischer j. 03.02.2015). ASSIM, NO CASO EM ANÁLISE, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, consoante art. 33º, § 2º, "c" do Código Penal (não reincidente e pena inferior a quatro anos).
Presentes os requisitos legais, substituindo somente a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.
Assim, a pena perfaz o montante de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no menor valor, substituída a pena corporal por PRD, nos termos retro.

III - Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JACKSON APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, devendo cumprir a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no menor valor, substituída a pena corporal por PRD, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 1 (UM) salário mínimo a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

A considerar a natureza da pena imposta, bem como a primariedade, CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade.

Custas na Forma da lei, visto que a ré é beneficiária da Lei nº. 1.060/50.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi. Declaro o perdimento do numerário apreendido, vez que não foi comprovada sua origem lícita, bem como do objeto apreendido nos autos (celular), encaminhando-o para destruição.

P.I.C.

Penápolis, 18 de fevereiro de 2022.

HEBER GUALBERTO MENDONÇA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA